

1503036-38.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FELIPE LOPES SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MARCOS FELIPE LOPES SALES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra denúncia, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1503036-38.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503036-38.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FELIPE LOPES SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MARCOS FELIPE LOPES SALES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra denúncia, de fls. 56/58, que, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 13h45, na Rua Pardinho, nº 33, Munhoz Jr, nesta cidade e comarca de Osasco, MARCOS FELIPE LOPES SALES, qualificado a fls. 07, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Vinicius Ismael Moreira, traziam consigo, para

entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) invólucros plástico contendo 11,15 g (onze gramas e quinze centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), "maconha"; 08 (oito) invólucros plásticos contendo 1,12 g (um grama e doze centigramas) de cocaína; 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo 2,1 g (dois gramas e um centigramas) de cocaína, na forma de "crack", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12, laudo de constatação a fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Narra, ainda, a inicial acusatória que, segundo apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e ao adentrarem à Rua Pardinho, avistaram o adolescente Gabriel escondendo "algo" embaixo de um caminhão quebrado coberto por lonas. Diante disso, os milicianos decidiram fazer a abordagem, tendo localizado o estojo verde escondido por Gabriel embaixo do caminhão, o qual continha os entorpecentes acima descritos e um aparelho de telefone celular da marca Samsung.

Indagado, informalmente, o adolescente Gabriel afirmou que praticava tráfico de entorpecentes, sendo que as drogas lhe foram fornecidas por MARCOS, bem como o aparelho de telefone celular apreendido pertencia também a MARCOS e apontou MARCOS para os policiais em quanto ele pilotava uma bicicleta. Diante disso, MARCOS foi preso em flagrante e o menor apreendido, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida no dia 05 de abril de 2020, às fls. 78.

Auto de prisão em flagrante às fls. 1/2.

Auto de exibição e apreensão às fls. 12 e fotos dos entorpecentes às fls. 13.

Laudo de constatação às fls. 15/17 e laudo definitivo às fls. 59/61 e 114/116.

Laudo do estojo às fls. 79/81 e Laudo objeto às fls. 107/109 e 110/112.

Folha de antecedentes às fls. 34/37.

Em decisão de fls. 38 foi concedida ao acusado liberdade provisória. Alvará de soltura cumprido às fls. 42/43.

Oitiva informal do adolescente Gabriel às fls. 68.

Notificado (fls. 77), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 70/73.

Foi realizada audiência de instrução às fls. 118/122.

Às fls. 157 foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Gabriel, bem como foi designada audiência em continuação.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu, ao final, interrogado.

Em alegações finais (fls. 174/178), a acusação pediu a procedência do pedido nos termos da inicial.

Em alegações finais (fls. 182/191), a Defesa pediu a absolvição por inexistência de provas. Em caso de condenação, pena mínima, reconhecimento do redutor, regime diverso do fechado e restritiva de direitos.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

Consto que a análise das premissas fáticas e jurídicas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a responsabilidade penal do réu. Não logrou o Ministério Público superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável, conforme passo a expor.

Em que pese a materialidade esteja demonstrada nos autos por meio boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de objeto (fls. 107/109) e laudo químico toxicológico (fls. 59/61), a autoria da conduta de trazer consigo drogas não está suficientemente demonstrada nos autos.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

Cumprido pontuar, nesse prisma, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Uma das regras legais de valoração racional da prova vem insculpada no art. 155 do CPP. Este comando legal, a seu turno, estabelece limites ao livre convencimento objetivo do juiz, na medida em que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que, quanto às provas orais, sejam elas avaliadas em contraditório judicial.

Anoto que, embora o art. 33, “caput” trate-se de tipo penal misto alternativo, a imputação será analisada sob o espectro da conduta de “trazer consigo”, conforme descrito na inicial.

A sentença, portanto, é fundamentada no fato de que a versão dos policiais não é suficiente a ponto de demonstrar e justificar a imputação jurídica de tráfico de drogas ao réu, retratada no verbo núcleo típico "trazer consigo".

No caso dos autos, as provas são eminentemente orais e não houve a produção de prova – sujeita ao crivo do contraditório – que permita a demonstração, para além de qualquer dúvida racional-objetiva, das premissas fáticas da acusação.

O réu, quando interrogado, permaneceu em silêncio. Deste fato não é possível derivar qualquer consequência jurídica. As provas, por outro lado, não são suficientes a superar o postulado constitucional da presunção de inocência.

Os policiais ao serem ouvidos em juízo confirmaram que viram o menor sob a lona do caminhão tentando esconder algo. Ao ser abordado o menor confirmou que se tratava de drogas, as quais foram localizadas pelos policiais.

Assim, quanto ao encontro das drogas pelos policiais não há dúvidas.

Entretanto, as provas não demonstram que o réu também trazia as drogas. Em primeiro lugar, o único elemento probatório seria a versão do menor que, tem tese, confirmaria que as drogas lhe haviam sido entregues pelo réu. Contudo, este menor não foi ouvido durante o contraditório tendo em vista a desistência do Ministério Público (fls. 148). Em segundo lugar, segundo as próprias testemunhas, no celular encontrado com o menor havia foto de Marcos. Quanto a este ponto, ainda que superado o problema de legalidade do acesso ao aparelho celular – o qual as testemunhas não souberam esclarecer – não houve qualquer investigação da polícia civil quanto ao conteúdo do celular para demonstrar qualquer vínculo entre o menor e o réu. Em terceiro lugar, a simples indicação do menor – não ouvido em contraditório – relativamente ao réu que, no momento, estava de bicicleta, não é suficiente a demonstrar a conduta típica. Por fim, em quarto lugar, as provas não demonstram qualquer vínculo subjetivo entre o menor e o réu a ponto de a ambos poder ser imputada a conduta de trazer consigo drogas destinadas ao consumo de terceiros.

Portanto, não tendo havido investigações para além do flagrante a indicar a conduta do réu, já que os policiais apenas avistaram-no andando de bicicleta, a absolvição se impõe.

Portanto, não logrou o Estado-acusação demonstrar suas premissas fáticas.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO o acusado MARCOS FELIPE LOPES SALES da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Determino a destruição do entorpecente. Oficie-se.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público.

Osasco, 11 de julho de 2022.